

1505447-75.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas na residência do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a denúncia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505447-75.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505447-75.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2019860/2019 - 97º Distrito Policial -

Americanópolis, 392/2019 - 26º Distrito Policial - Sacomã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN HENRIQUE DA SILVA MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 613/20

VISTOS.

JHONATAN HENRIQUE DA SILVA MOREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta, que no dia 18 de janeiro de 2019, sexta-feira, por volta das 23h20min, na Rua Rolando Curti, 88, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca, mantinha em depósito, para consumo de terceiros, 651,7 gramas de cocaína, na forma de crack (cocaína), fracionadas em 1.300 unidades e uma sacola; 8.116,5 gramas de Tetrahydrocannabinol, divididos em 350 (trezentos e cinquenta) unidades de Skank, 129 (cento e vinte e nove) invólucros plásticos 02 (duas sacolas) e 01 tijolo de substância vulgarmente conhecida como maconha, mais 16.5 litros de cloreto de metileno, conhecido como

lança-perfume, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls. 139/140.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, três testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu preliminarmente a nulidade do feito pela invasão feita na residência do réu, tratando-se de prova ilícita. No mérito, a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da minorante, a pena no mínimo, regime mais brando e direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

Afasto de plano a preliminar arguida pela Defesa do réu, uma vez que a presente ação penal transcorreu de forma legal e regular, nada havendo nos autos, capaz de maculá-la de vício insanável.

Com efeito, não há que se falar em nulidade da ação penal em decorrência de prova ilícita. Fato é que os policiais localizaram grande quantidade de drogas no interior da residência do réu, fato que por si só, já é suficiente a legitimar a ação dos policiais.

Não se ignora os preceitos constitucionais trazidos a baila pela Defesa, segundo os quais a casa é asilo inviolável, a menos que no interior dela esteja ocorrendo um crime.

Embora não tenha ocorrido a prisão em flagrante do réu, fato é que as drogas foram apreendidas no interior da residência do acusado, o qual, identificado posteriormente, acabou sendo preso preventivamente por este feito, quando preso em flagrante por outro processo, também de tráfico de drogas.

Desta forma, temos que o encontro das drogas legitimou a ação dos policiais, pelo que, não há que se falar em nulidade da ação penal.

E ainda: "A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio admite exceções. Não protege indivíduo em atividade criminosa no recesso da habitação, como é o caso do traficante que esconde maconha dentro de casa. Aí é possível, qualquer que seja a hora, a prisão em flagrante, pois a guarda de substância entorpecente é crime permanente" (TJSC - RT, 508/435).

Superada a questão, a presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/10 dando conta dos 130 eppendorf's de cocaína, das 1300 pedras de crack, de uma sacola com pedra esfarelada de crack, dos 350 invólucros de skunk, dos 129 invólucros de maconha, dos 02 invólucros de maconha, de 01 tijolo de maconha, de 01 galão contendo Lança-Perfume, localizados e apreendidos em poder do réu.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 159/161, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para tetrahidrocannabinol, cocaína e tricloroetileno.

A autoria também é inconteste.

De fato, os argumentos de sua defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra ele derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações do próprio increpado que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Tanto na fase inquisitiva como em Juízo o réu exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Ocorre porém que as provas dos autos falam por si, e deixam inconteste de dúvida a traficância praticada pelo réu.

Veja que a gigantesca quantidade de drogas apreendidas estavam armazenadas na residência do acusado, tanto que quando da chegada dos policiais, a mãe dele se aproximou acreditando que seu filho seria preso, justamente por ali ser sua morada. Além disso, as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma

evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer.

Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado.

Desta forma, não se tem nos autos, um indício sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar o réu ou mesmo acusá-lo falsamente.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas na residência do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a denúncia anônima mencionando o nome e endereço do acusado, o encontro do seu aparelho celular e do RG de seu irmão no local, a grande quantidade e variedade de drogas encontradas, somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância.

Tanto é assim que os policiais militares responsáveis pela localização e apreensão das drogas, Douglas Alessandro Almeida Batista e Abmael Ribeiro da Silva, ouvidos em Juízo, relataram em uma só voz, de forma firme e segura que recebemos essa denúncia através do setor reservado, dizendo que no local, um indivíduo de nome Jhonatan estaria armazenando drogas e preparando o material para ser vendido. Fomos ao local dos fatos, que era uma residência aparentemente abandonada, que estava com a porta aberta. As drogas estavam na residência, em cima de objetos bem velhos. Não tivemos contato com o réu. A denúncia fornecia detalhes sobre o local onde as drogas estariam armazenadas. Quando nós estávamos no terreno, procurando o local, a mãe e a irmã do réu apareceram, acreditando que ele seria preso. Também foi localizado o aparelho celular do réu e um RG, que posteriormente soubemos que era do irmão do réu.

Os policiais militares narraram com segurança e precisão como se deu a localização das drogas, relatando todos os detalhes, desde apuração de denúncia anônima a fim de apurar armazenamento de drogas por parte do réu em sua residência, o momento em que sua genitora se fez presente, o encontro das drogas e apetrechos, a apreensão do aparelho celular do réu que não estava presente no imóvel, até final apreensão dos entorpecentes.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ª T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar

desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311). Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, alegando em síntese que tudo não passou de uma armação para incriminar o réu e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

O irmão do réu, Matheus Cristiano, ouvido em Juízo como informante, declarou que como eu trabalhava o dia inteiro, não tinha ciência que tinha essas drogas lá. Como morávamos só nos dois, e a droga não era minha, só pode ser dele.

Veja que o próprio irmão do réu confirmou o encontro das drogas pelos policiais na residência em que moravam. Chegou a relatar que só moravam os dois no local, e que as drogas não eram suas, então, somente poderiam ser do réu.

Neste contexto, em vista da grande quantidade e variedade de drogas encontradas em poder do réu, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercância, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição.

Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. Nesta primeira fase, vejo que o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, já condenado de forma definitiva pela prática de crime da mesma espécie, demonstrando possuir uma personalidade desvirtuada da moral média e com tendência à traficância. Tais circunstâncias não podem ser ignoradas e atuam de forma desfavorável ao condenado.

Desta forma elevo sua pena base em 1/6, perfazendo, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase, o réu é multirreincidente específico, conforme certidões de fls. 136/137. Assim, aumento sua pena em mais 1/6, para, não havendo outras circunstâncias, tornar a pena definitiva, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa. O valor de cada dia multa será o mínimo legal.

Não há que se falar em aplicação da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que o condenado, é reincidente específico, foi condenado pelo armazenamento de gigantesca quantidade e variedade de drogas, circunstâncias estas suficientes a afastarem os requisitos subjetivos necessários para o reconhecimento e aplicação da redução em apreço, nada havendo portanto, que demonstre que não faz do crime um meio de vida.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que " O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de crack - justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3" (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). Pelo mesmo motivo, incogitável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxico, tendo em vista circunstância

judicial desfavorável atinente à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (TJESP, Apelação Criminal nº 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO; STF, RHC 94.806/PR; STJ, HC 105.216/SP e 141.921/SP), porquanto o expressivo (e variado) “carregamento” denota estreita vinculação do réu com organização destinada ao tráfico.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar JHONATAN HENRIQUE DA SILVA MOREIRA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente fechado, a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

O condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade fechado, pois além da reincidência, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime tido como hediondo e o artigo 2º, §1º da Lei 8072/90 prevê expressamente, que crimes dessa natureza, terão suas penas cumpridas inicialmente em regime fechado. Além do mais, tratando-se de crime equiparado a hediondo, elencado pela Constituição Federal como inafiançável, sendo vedada a liberdade provisória, antes da condenação definitiva, quando prevalece a presunção de inocência, muita mais descabida é a concessão de qualquer regime diverso, com possibilidade de liberdade cautelar àquele que vem a ser condenado, mesmo que em primeiro grau. Não é possível também a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social.

Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: “Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: “inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (inciderent tantum).”

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida. Além disso, não encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício, uma vez que o crime em apreço possui natureza gravíssima, cujas circunstâncias caracterizadas pelo lucro fácil em detrimento da saúde das pessoas de nossa sociedade, e as consequências do delito que levam à desestabilização familiar e social, indicam que a substituição não se mostra suficiente como forma de retribuição estatal. Qualquer outra pena, que não a privativa de liberdade e em regime fechado, mostrar-se-ia por demasiado tênue, como forma de repressão e retribuição.

De forma idêntica, a Resolução nº 05/12, do Senado Federal, também não obsta aquele posicionamento, visto que o artigo 44, “caput”, da Lei de Tóxicos permanece íntegro. Trata-se ainda de crime equiparado aos crimes hediondos, não tendo assim, referida Resolução retirado o caráter hediondo do crime, circunstância que levou o legislador constituinte a prever um tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas. Em arremate, o condenado respondeu a todo o processo preso e assim deve permanecer, pois foi nesta data condenado a crime de extrema gravidade, dos quais não se admite

liberdade provisória, ex vi do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06. A sociedade está aterrorizada com o crescente aumento da criminalidade, em especial, da prática de crimes como deste jaez, cujos agentes não se privam em aliciar jovens em nossas comunidades, causando transtornos irreparáveis em todos os cidadãos de bem.

Assim sendo, presentes os requisitos legais, não concedo ao condenado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime.

No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se o réu no estabelecimento prisional que se encontra recolhido.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA